

1502284-13.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502284-13.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502284-13.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2311368/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 21408534 - 03º D.P.

DIADEMA, 2311368 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Marcelo Henrique Borge da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

MARCELO HENRIQUE BORGE DA SILVA, qualificado às fls. 09/11, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 07h30, na Travessa Amazonas, altura do nº. 10, no bairro do Taboão, nesta cidade de Diadema, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 202 embalagens plásticas contendo 131,02g da droga cocaína, 312 embalagens plásticas contendo 52,46g da mesma droga, na forma de crack, e 124 embalagens plásticas contendo 131,76g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 18 e laudo de constatação provisória de fls. 15/17, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19/01/2022 (fl.82), sem proposta de transação penal. Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 30/33), seguiu-se com a notificação e citação do réu (fl.66), a quem foi nomeado Defensor Público que ofertou defesa inicial as fls.68/69.

Em audiência uma foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal diante da excessiva quantidade e variedade de drogas altamente nocivas como o crack e cocaína, com a atenuante da confissão, mas sem possibilidade de redução da pena nem sua substituição ante a alta quantidade e nocividade da droga, devendo a pena cumprida em regime fechado, sem direito de apelo em liberdade, mais a perda do valor apreendido posto que proveniente do tráfico.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, e o redutor máximo da pena, fixando-se regime mais brando e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, com direito de apelo em liberdade até pela detração penal. É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem no auto de exibição e apreensão de fls.18/22, laudos de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha e cocaína (respectivamente às fls.15/17 e 63/65), além da apreensão de numerário proveniente da mercancia ilícita (R\$102,00 - fl. 18).

A autoria é incontestada conforme prova que sigo analisando.

Os policiais militares afirmaram em solo pré-processual (fls.07/08) que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Canhema, dirigindo-se à Travessa Amazonas, local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Que ao acessarem referida rua, avistaram um indivíduo que ao perceber a presença policial demonstrou inquietude e nervosismo, andando para o lado oposto a eles, na tentativa de empreender fuga. Proferiram voz de parada ao indivíduo, sendo ele identificado como Marcelo Henrique Borge da Silva. Procedida a busca pessoal, localizaram na sua posse, no interior do bolso de sua calça a quantia de R\$102,00 em espécie, 6 invólucros com substância aparentando cocaína e 12 invólucros contendo substância aparentando crack. Questionaram Marcelo, afirmando ele que estava traficando drogas naquele local e indicou o local onde estaria uma sacola com entorpecentes. No local indicado localizaram uma sacola contendo 124 tabletes de erva esverdeada aparentando de maconha, 196 invólucros plásticos contendo substância em pó branca aparentando cocaína e 300 invólucros plásticos contendo pedras amareladas aparentando Crack.

Em juízo o policial Gustavo Teixeira reiterou que o local é um ponto conhecido de venda de entorpecentes. O réu os viu e saiu andando no sentido oposto da viatura. Alcançado e revistado, com ele estavam as drogas e o dinheiro. Ele confessou que estava vendendo os entorpecentes, e disse o quanto ganhava. Ele ainda indicou um relógio de registro de água onde localizaram e apreenderam mais drogas embaladas igualmente como as com o réu, mais de cem invólucros de cada tipo, era bastante coisa. Foi a primeira vez que viu o acusado no local. Reconhece o réu

Neste sentido foi o depoimento do policial Thiago da Silva Ré confirmou que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado parado na rua e ao ver a equipe, andou

em passos largos. Abordado e revistado, localizaram com ele pedra de crack e cocaína, além de dinheiro. Questionado, ele confessou que estava vendendo entorpecente e questionado se havia mais drogas, ele indicou um relógio de água tinha mais entorpecentes iguais aos que estavam com ele, em bastante quantidade. Reconhece o réu e foi a primeira vez que viu o réu foi visto na biqueira.

O réu, extrajudicialmente (fl.09), confessou a prática da traficância, detalhando que é usuário de drogas e vendia os entorpecentes pelos valores de R\$5,00 a R\$10,00, recebendo o valor correspondente a 10% sobre as vendas do dia.

Sob o crivo do contraditório o acusado confessou que estava mesmo vendendo drogas, das três às nove da manhã. O dinheiro apreendido era da venda de drogas que já tinha feito em seu primeiro dia de trabalho. Não foi processado antes. É usuário de cocaína. Está arrependido. Às reperguntas, disse que estava em poder de drogas e o restante estava no relógio, embora não soubesse a quantidade certa delas, e que só pegaria quando as suas acabassem.

Logo, o interrogatório com a confissão do réu não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Assim como não procede a tese do réu de se tratar de mero usuário, posto que não demonstrado cabalmente como lhe competia o ônus dessa prova. Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl.18), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas por outro lado a excessiva quantidade de narcótico apreendido (638 no total), às vistas do disposto no art.42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo, qual seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, valendo-me dos princípios da proporcionalidade e

da razoabilidade. E aqui não se alegue que o réu não estaria portando todas as drogas e sim pouca quantidade dado que ele era o responsável e, portanto, guardava o restante num relógio de água e, portanto, com relação a tudo deve responder, mesmo se alegue desconhecer qual o montante exato, o que seria pouco crível dado que se assim o fosse, ele poderia ter que responder e ter que pagar por falta de drogas que eventualmente lhe cobrassem.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e sim a atenuante da confissão espontânea, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.51/53), mas considerando a natureza, ou seja, os tipos de drogas, especialmente a cocaína (e crack), e sua nocividade, alto poder viciante e degradante da saúde do ser humano, além da quantia em dinheiro apreendida (R\$102,00 - fl.18), demonstrativo de vendas efetivamente efetuadas a usuários como confessado pelo réu, quem assim disseminou, propagou e contribuiu para o vício de usuários, tudo a indicar seu maior envolvimento com a mercancia, opto pelo percentual de 1/3, a reduzir a reprimenda para 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP ao réu diante da excessiva quantidade de substâncias entorpecentes, por não se mostrar socialmente recomendável, tratando-se de uma ação de extrema gravidade. Some-se a isso o fato de que : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Fixo o regime prisional semiaberto por conta da grande quantidade e variedade das drogas valendo-me, como razão de decidir, das jurisprudências que seguem: Segundo entendimento do STJ já firmado, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e da quantidade da droga. Assim, fixo

regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena por considerar a enorme quantidade de 638 invólucros entre maconha, cocaína e crack, a autorizar o regime intermediário. E mais: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há quatro meses, sem direito portanto sequer à progressão de regime.

O posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu, ora condenado a regime que o manterá preso para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. Inclusive: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado, e sim a se determinar a perda do dinheiro proveniente do crime.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra MARCELO HENRIQUE BORGE DA SILVA, qualificado às fls. 09/11, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a assistência

pela DPE.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 18), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias, sob as pena da lei.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA